

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（一）

第二十八講 參政權

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

參 政 權

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、參政權之內涵

一、UK_WC §15 (Right to Participate in Public Life and Service)

15. Every adult citizen has the right and the opportunity, without unreasonable restrictions
- .1 to take part in the conduct of public affairs ***directly*** or ***through freely chosen representatives***;
 - .2 to vote and to stand for election at genuine periodic elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the ***free expression of the will of the people***;
 - .3 to ***participate***, on general terms of equality, ***in public service***. (平等服公職權) 

二、ICCPR §25 (The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service) &

General Comment No. 25 (1996/07/12) 

三、Checklist/ IV. A. **Political rights**

- 1. Right to form political parties (組黨權)
- 2. Right to take part in public affairs, ***directly*** or ***through freely***

《對話憲法・憲法對話》2016

chosen representatives（直接、間接參政權）

3. Right to vote and be elected（選舉權及被選舉權）
 - a. Genuine, periodic elections
 - b. Universal, equal suffrage
 - c. Secret ballot
4. Right of access to public service（服公職權）
5. Right of access to government information（政府資訊公開請求權 = 資訊受益權，詳☞詳 30 講）
6. Right to communicate and to publish（「言論自由權」）
 - a. Right to establish radio and TV stations
 - b. Right to access to government-owned mass media
 - c. Prohibition against censorship
7. ***Role of electoral commission*** 

貳、參政權之意涵

一、性質

1. G. Jellinek「國民地位分類論」人民「主動」（參與形成國家意思）的關係
2. 孫中山「權能區分」
政權（§17） v. 治權（統治權力）
 - 2.1 在國民主權國家（憲法前言；§§1, 2），除「選舉權」得為「間接選舉」外，其餘「政權」（＝「政治主權」political sovereignty）不能委由「代表」代為行使！
 - 2.2 「代表」只能代表人民行使「治權」（＝「法律主權」legal sovereignty）→ 準此，憲 §25 顯有可議
3. 直接民主的憲法基礎

- 3.1 §17 參政權之範圍包含「創制、複決」
- 3.2 §136 實現創、複兩權乃憲法所明定的（憲法委託），乃必要的「制度性保障」（Cf. §24）；惟，其「內容」並受「法律」之限制（兩者乃相互制約之關係）

二、參政權概念

1. 傳統意義參政權

1.1 狹義參政權：選舉、罷免、創制、複決（§17 & 12 章）

- §129：「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之」。
- §130：「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權」。

Q Age discrimination, unconstitutional on its face?

- §131：「本憲法所規定各種選舉之候選人，一律公開競選」。
- §132：「選舉應嚴禁威脅利誘。選舉訴訟，由法院審判之」（“Free expression of the will of the People”）。

Q 此二條之目的？

Q 何以規定選舉訴訟由法院管轄？

- §133：「被選舉人得由原選舉區依法罷免之」。

Q 何以限制由「原選區」罷免？

- §134：「各種選舉，應規定婦女當選名額，其辦法以法律定之」。

Cf. §§ 26-(7), 64-II→ 增修 §4-II-(3)

Q 此為積極（兩性）平權措施？抑對婦女之歧視？

Cf. 釋字 649（身心障礙者保護法 §37-I 限制按摩業

僅得由視障者從事，違憲)

釋字 719 (政府採購法規定：得標廠商其國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用原住民至少(達其國內員工總人數的)百分之一，合憲)

Q 「積極平權措施」是誰歧視誰？與一般「歧視」有無不同？

- §135：「內地生活習慣特殊之國民代表名額及選舉，其辦法以法律定之」。(Cf. §5)
- §136：「創制複決兩權之行使，以法律定之」。

1.2 廣義參政權 = 狹義參政權 + 應考試服公職權 (§18)

- 釋字 715

解釋文：招生簡章規定「曾受刑之宣告者，不得報考國軍志願役預備軍、士官班」，無違「法律保留原則」，但牴觸比例原則。

〈湯德宗大法官_部分協同暨部分不同意見書〉

1.「應考試服公職權」為一項憲法權利，「應考試」與「服公職」具有手段與目的之關聯，不存在單獨的「服公職權」。「應考試服公職權」與「工作權」之關係，詳如附圖。2.「應考試服公職權」為廣義之參政權，其限制應適用與參政權限制相同程度之「法律保留」原則

- 釋字 605 (服公職權之制度性保障)

解釋文：「憲法第十八條規定人民有服公職之權利，旨在保障人民有依法令從事於公務，暨由此衍生享有之身分保障、俸給與退休金等權利」

Cf. 釋字 575 (戶警分立實施方案)

釋字 483（官等俸級）

調任雖無降級或減俸之名，實際上亦不得生類似降級或減俸之懲戒效果

- 釋字 491（不受恣意免職之保障）
公務員免職之事由應由法律規定，
免職之程序須符合正當程序
- 釋字 583
考績免職（懲處處分）亦屬懲戒處分，應類推適用懲戒權行使期間之限制（十年）
- 釋字 283
「特赦」效力包括「回復」因有罪判決確定而喪失，
並有向將來回復之可能之公職

2. 現代意義的參政權

2.1 行政程序之參與

- 行政立法（法規命令 *Rechtsverordnungen*, legislative rules＝傳來立法 *secondary legislation*）程序之參與
行政程序法 §§154 ff. (notice & comment procedures)

2.2 立法程序之參與

- 立法公聽會（立法院職權行使法 第 9 章 §§54～59
委員會公聽會）
- 立法院請願（立法院職權行使法 第 11 章 §§ 64～67
請願文書之審查）
- 遊說法（96/08/08）

2.3 司法程序之參與

- 放寬原告適格（standing），創設「公民訴訟」（citizen suits），俾便以訴訟挑戰行政決定（行政處分）

《對話憲法・憲法對話》2016

E.g., 高高行 96 訴 647 (開發行為總面積為 6 公頃，業者與主管機關將整個開發行為分割為許多小部分，每部分均小於 1 公頃，分別申請開發許可，主管機關並以此為由認無須進行環評。法院認為應以全體開發行為計算開發計劃之面積，爰命業者停止開發，補行環評程序)

- 開放人民憲法訴願，挑戰終局裁判認事用法之合憲性

2.4 政府資訊公開請求權 (詳 30 講)

湯德宗，〈政府資訊公開請求權入憲之研究〉，載《憲法解釋之理論與實務》第五輯，頁 261~291 (2007 年 3 月)。

3. 參政權與民主理論

Q 參政旨在追求什麼樣的民主？

參、參政權的限制

公職人員選舉罷免法 (105/04/13，下稱「選罷法」)

總統副總統選舉罷免法 (98/05/27，下稱「總統選罷法」)

一、選舉權

1. 中央民代定期改選之中止與恢復
釋字 31 & 261
2. 年齡限制
憲 §130；選罷法 §14，總統選罷法 §11
3. 選區居住期間之限制
選罷法 §15 (四個月)；總統選罷法 §12 (六個月)
4. 精神狀況之限制 (未受監護宣告)
選罷法 §14；總統選罷法 §11

選舉乃個人意願之表達，自以具有表意能力為其前提

二、被選舉權（競選公職權）

1. 學經歷限制

釋字 290

2. 年齡限制

憲 §130（須滿 23 歲），選罷法 §24（須滿 26, 30 歲）；

憲 §45（須滿 40 歲），總統選罷法 §20（須滿 40 歲）

3. 資格限制

3.1 積極資格（設籍、國籍等）

選罷法 §24-VII

總統選罷法 §20（設籍滿十五年，非歸化國民，非陸港澳人民）

3.2 消極資格

選罷法 §26（犯罪前科），§27（身份限制）

總統選罷法 §26（犯罪前科），§27（身份限制）

4. 財產限制

4.1 連署門檻及連署保證金 釋

字 468；總統選罷法 §23-I

4.2 參選（登記）保證金

釋字 340；選罷法 §32；總統選罷法 §31

5. 等待期間（罷免案通過者）

選罷法 §92-I；總統選罷法 §78-I

三、罷免權

1. 對象

釋字 331（政黨比例代表得由所屬政黨罷免）

釋字 401（罷免旨在追究政治責任≠免除法律責任之言論

免責特權)

2. 等待期間

選罷法 §75-I (就職未滿一年者，不得罷免)

Q何以限於「原選區選民」始得提議？總統

選罷法 §70 (就職未滿一年者，不得罷免)

Q人民得自行提案？

選罷法 §92-II (罷免案經否決者，任期內不得再提議罷免)

總統選罷法 §78-II (罷免案經否決者，任期內不得再提議罷免)

四、選制設計

1. 政黨比例代表之限制？

釋字 499 (不得為全額；不得以其他選舉之結果為計算基礎)

Q民意機關之政黨比例代表有無比例限制？

Cf. 釋字 261 (理由書)

2. 釋字 721 (憲法增修條文第四條第一項及第二項關於單一選區兩票制之並立制、政黨比例代表席次及政黨門檻規定部分，並未違反現行憲法賴以存立之自由民主憲政秩序)

五、創制權 (公民投票法 (98/06/17))

1. 全國性公投

公投法 §2-II-(2) (立法原則之創制)

2. 地方性公投

公投法 §2-III-(2) (地方自治法規立法原則之創制)

公投法 §31-I-(1) (三個月研擬法案，議會次一會期審竣)

六、複決權

1. 全國性公投

公投法 §2-II-(1) (法律之複決)

公投法 §2-II-(4) (憲法修正案之複決)

2. 地方性公投

公投法 §2-III-(1) (地方自治法規之複決)

公投法 §§ 31-I-(3), (4)

七、政策公投

釋字 645 (立法院提議公投之規定, 合憲)

1. 全國性公投

公投法 §2-II-(3) (重大政策之創制或複決)

2. 地方性公投

公投法 §2-III-(3) (地方自治事項重大政策之創制或複決)

公投法 §§31-I-(3)

八、應考試服公職之限制

1. 須「應考試」始能取得公務人員(常任文官)之任官資格
(憲 §86)

2. 應考資格限制(年齡、體格、性別等)之合憲性?

肆、選舉訴訟

一、審級

釋字 442 解釋(二審終結不得提起再審之限制, 合憲)

二、權利保護之必要(原告適格)

釋字 546 (性質上屬於重複發生之權利或法律上利益, 人民因參與或分享, 得反覆行使者, 仍有權利保護之必要)

三、審查基準選擇

吳敦義競選緋聞錄音案:

高雄地院 98 訴字第 1081 號判決、臺灣高院高雄分院 99 年
上字第 203 號判決、最高法院 102 年台上字第 644 號判決、

《對話憲法・憲法對話》2016

臺灣高院高雄分院 102 年度上更（一）字第 8 號判決、最高法院 105 年度台上字第 143 號裁定。

黃俊英競選走路工案：

高雄地院 96 年選訴字第 10 號判決、臺灣高院高雄分院 97 年度選上訴字第 1 號判決、最高法院 97 年台上字第 5997 號判決、臺灣高院高雄分院 97 年度上更（一）字第 18 號判決、最高法院 98 年度台上字第 4582 號判決。

【學思策問】

Q 相較於他國，我國大法官解釋對於「參政權」限制之審查標準是否偏低？何故？

Q 法院對於選舉訴訟應採如何之審查基準？

【進階閱讀】

湯德宗，〈論直接民主的制度設計-- 行政院版「創制複決法」草案評析〉，輯於氏著，《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 241～322（2014 年，增訂四版）。

張千帆，〈選舉公正的司法保障-- 論負面競選的審查標準〉，《憲政時代》，第 32 卷第 4 期，頁 495～543（2007 年 4 月）。

Heather K. Gerken, *Understanding the Right to an Undiluted Vote*, 114 HARV. L. REV. 1663 (2001).

【課後習作】

憲法第一百三十條所定年齡限制，合憲？相關法律提高憲法所定參政權年齡限制者，違憲？

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
483	15. Every adult citizen has the right and the opportunity, without unreasonable restrictions .1 to take part in the conduct of public affairs directly orthrough freely chosen representatives... to participate, on general terms of equality, in public service.		The Institute for Public Policy Research , 《 The Constitution of the United Kingdom 》 P184-185 (http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1) 瀏覽日期：2016/10/6， 本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。
483	(The right to participate in public affairs...General Comment No. 25 (1996/07/12)		《International Covenant on Civil and Political Rights》本作品屬公共領域。
483-484	1. Right to form political parties 2. Right to take part in public affairs, directly or...7. Role of electoral commission		Albert P. Blaustein , 《Framing the Modern Constitution: A Checklist》本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。